

1500755-57.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500755-57.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500755-57.2020.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOAO VITOR DONIZETTI DE MORAIS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Em cumprimento à ordem em habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de João Vítor Donizetti de Moraes, passo a dosar novamente a pena conforme determinado.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, para ambos os réus, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação ao réu João Vitor, anoto que as atenuantes da menoridade e da confissão não podem trazer a pena-base aquém do mínimo legal. Não há agravantes. O réu é primário (fls. 54). Em relação ao réu Maurício, anoto não haver agravantes ou atenuantes. O réu é primário (fls. 57/58).

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida uma causa de aumento de pena (artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias multa.

Ainda na terceira fase, sendo os acusados primários (fls. 54 e 57/58) e não havendo indicação de que integrem organização criminosa, além de não haver qualquer prova no sentido de que ele se dedique ao tráfico de forma contumaz e permanente, considerando, ainda, que a quantidade de entorpecente com ele encontrada não é expressiva e/ou diversificada, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduz a sua pena em 2/3 (dois terços) resultando, em definitivo, 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Cabe destacar que em caso análogo, no qual o réu transportava cerca de 990 gramas de cocaína, houve determinação do STF, em sede Recurso Ordinário de Habeas Corpus n. 197905, para aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Há vários outros precedentes desta Corte e do STJ neste sentido, ou seja, quantias mais expressivas de droga com o reconhecimento do privilégio.

Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da atual jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixada, quando do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, a elevada quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. Portanto, inexistentes outras características da conduta deletéria aptas a amparar conclusão nesse sentido, tal como ocorreu na espécie, não há falar em afastar o benefício ou modular a fração dessa aquém do mínimo legal. 2. Agravo regimental desprovido.". (STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 , julgado em 17/08/2021)" - grifei

No mesmo sentido decidiu o TJSP, em julgamento de caso originado nesta Vara Criminal, apreensão de 5,77 kg de maconha ao dispor que: "Porém, em que pese estivesse o réu a transportar expressiva quantidade de droga, quase seis quilos, a prova produzida na instrução nada revelou quanto ao envolvimento dele com organização criminosa ou que se dedicasse com habitualidade à prática de crimes, motivo pelo qual cabe aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, adotando-se o índice de um sexto, considerada a quantidade do entorpecente, que permitiria atingir grande número de usuários, de tal modo a se alcançar um total definitivo de quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, o que inviabiliza a imposição de sanções alternativas, as quais, na hipótese, nem seriam socialmente recomendáveis" (Apelação Criminal 1500824-89.2020.8.26.0548; Relator: Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2020) - grifei.

Por fim, em caso análogo, também em julgamento de caso originado nesta Vara Criminal, apreensão de 838 porções de cocaína, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de drogas Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Pena-base fixada no mínimo - Confissão do réu - A quantidade de drogas somente deve ser considerada na primeira fase de aplicação da pena e não impede a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa - RECURSO DA DEFESA PROVIDO" (Apelação Criminal 1501577-46.2020.8.26.0548; Relator: Heitor Donizete De

Oliveira ; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19 de outubro de 2021) - grifei.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Estendi a benesse ao corréu Maurício, pois sua situação é idêntica à do paciente, por medida de economia processual.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os réus JOÃO VITOR DONIZETTI DE MORAIS e MAURICIO ANDRADE DA SILVA FERNANDES a cumprirem pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, por ter violado o artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o montante da pena fixado e, também, levando em consideração tratar-se de tráfico privilegiado e de pequenas proporções, será o ABERTO. Poderão os acusados aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Ainda, anoto ser possível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos para ambos acusados. Justifico.

O Supremo Tribunal Federal (HC 97.256) reconheceu a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da lei 11.343/06 (...vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos). Vale frisar, inclusive, que a Corte maior no julgamento do HC 111.840 declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei 8.072/90, o qual prevê que a pena para o crime de tráfico será cumprida inicialmente em regime fechado. Vale citar alguns julgados sobre o tema: "(...) a partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do referido HC nº 97.256/RS, em que se admitiu a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, impõe-se, neste caso, a adequação também do regime, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção penal, com a fixação de regime prisional mais brando, compatível com a benesse concedida justamente para evitar o encarceramento" (STJ, HC nº 237.074/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.5.2012). "Nesse contexto, nas hipóteses em que se verificar a viabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em medida restritiva de direitos, não deve existir impedimento para a fixação do regime inicialmente aberto no cumprimento da pena." (STJ, HC 213.288/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 22.5.2012). "(...) a Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com previsto no art. 33 do Código Penal (HC nº 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos." (STJ, HC nº 189.931/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.5.2012). "Ocorre que, em recentes julgados, esta Segunda Turma concedeu a ordem a pacientes condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com afastamento da regra do art. 2º, §1º, da Lei. 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determina o cumprimento no regime inicial fechado, para permitir-lhes que iniciem o cumprimento das suas reprimendas no regime aberto, porque presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art.33, II, c, do Código Penal" (STF, HC 109.343/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, v.u., j.03.4.2012)".

Mais recentemente, o STF reconheceu no julgamento do Habeas Corpus 125.188 a possibilidade de concessão de regime aberto com substituição da pena corporal pela restritiva em casos de tráfico privilegiado. Ainda, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 600, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou entendimento, aliando-se ao que foi decidido pelo STF no HC 118.533/MS, que o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo.

Assim, ante tais decisões da Corte Suprema e do STJ, o magistrado deve analisar, caso a caso, os requisitos legais para a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, especificados no artigo 44 do Código Penal. Dispõe o inciso VI do mencionado artigo ser possível a substituição quando todas as circunstâncias previstas forem favoráveis, inclusive culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Não se olvide que o tráfico de drogas é o tipo de crime em que seus agentes estão sempre escalonados em hierarquia que vai dos pequenos traficantes de rua aos grandes chefes que comandam uma organização. Assim, é necessário aferir, no caso concreto, qual a situação exata do condenado.

No caso em tela, não há prova de que o sentenciado integre organização criminosa e seja dela membro importante ou ocupante de função de relevo. Por fim, foi reconhecido o tráfico privilegiado. Portanto, possível a substituição da pena corporal ante o preenchimento de todos os requisitos legais.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade imposta aos acusados por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução.

Expeçam-se alvarás de soltura, clausulados.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 18 de agosto de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA